

1500091-30.2022.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ HENRIQUE ANTICO

Comarca: Roseira

Foro: Foro de Roseira

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... de que o filho estava atuando no tráfico de drogas e que não tinha emprego - JULIANA APARECIDA RODRIGUES AGUIAR - fls. 170 - audiência gravada pelo sistema Teams.

Não resta a menor dúvida de que as drogas apreendidas naquela oportunidade pertenciam ao acusado e eram destinadas ao tráfico, inversamente do que tentou fazer crer a combativa defesa. A quantidade apreendida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Roseira

Foro de Roseira

Vara Única

Rua Dom Epaminondas, 54, Roseira-SP - cep 12580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500091-30.2022.8.26.0621 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500091-30.2022.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026124/2022 - DEL.POL.ROSEIRA, 22705747 - DEL.POL.ROSEIRA, 30/22/206 - DEL.POL.ROSEIRA, 2026124 - DEL.POL.ROSEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO RODRIGUES AGUIAR

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ HENRIQUE ANTICO

V I S T O S.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pela Justiça Pública contra PEDRO RODRIGUES AGUIAR, devidamente qualificado nos autos, apontando-o como transgressor do disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 15h00, na Praça João Paulo II, Parque das Rosas, nesta cidade, o acusado, trazia consigo, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, oito microtubos tipo eppendorf contendo substância vulgarmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 12,23g, e quatro trouxinhas contendo cocaína em sua forma petrificada, vulgarmente conhecida como "crack", pesando aproximadamente 5,3g, substâncias capazes de causar dependência física e

psíquica, conforme laudo pericial. Ainda segundo a acusação lançada, nas mesmas circunstâncias mencionadas acima, no interior da residência localizada na Rua Benedito Vieira Cruz, nº 2017, bairro Vila Roma, nesta cidade, o réu tinha em depósito, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, dezenove microtubos tipo eppendorf contendo substância vulgarmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 24,68g, e 21 trouxinhas contendo cocaína em sua forma petrificada, vulgarmente conhecida como "crack", pesando aproximadamente 10,19g, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, de acordo com laudo pericial. Segue a peça acusatória narrando que o réu recebera grande quantidade de entorpecentes com o objetivo de comerciá-los, razão pela qual se postou no local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas na cidade. Ocorre que moradores perceberam a ação e o denunciaram à polícia, que em diligência pelo local observaram quando o acusado dispensou um carteira de cigarro, em cujo interior havia oito microtubos de cocaína, além de quatro trouxinhas de "crack". Em busca pessoal a Polícia Militar encontrou a quantia em dinheiro de R\$ 54,50. Dando prosseguimento às diligências, os policiais seguiram para a residência do acusado, sendo que após terem a entrada franqueada localizaram no quarto do acusado, no interior de um guarda-roupas, mais dezenove microtubos de cocaína e outras vinte e uma trouxinhas de "crack", além de um aparelho de telefonia celular da marca "Samsung", aparentemente danificado. Conclui dizendo que o envolvimento do réu com o narcotráfico se deve às circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento e quantidade das drogas. Requereu, por fim, o perdimento do dinheiro apreendido, na forma do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Por meio da decisão de fls. 110 a liberdade provisória concedida ao acusado foi revogada, diante do descumprimento das medidas cautelares estabelecidas.

Em cumprimento ao disposto no artigo 55 da Lei nº 11.343/06 o acusado foi notificado e apresentou a defesa preliminar de fls. 140, sem preliminares, exceções ou rol de testemunhas.

Denúncia ministerial acolhida pela decisão de fls. 144.

Durante a fase de instrução processual foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público (fls. 169 a 172). O réu foi interrogado à fls. 174, confessando a traficância e a vinculação com os entorpecentes apreendidos.

Em sua derradeira manifestação o Ministério Público propôs a condenação do acusado, apoiando-se no acervo probatório compilado pela instrução criminal. Sustentou que os depoimentos dos policiais deram conta da autoria do delito de tráfico por parte deste agente, somados ao encontro da droga, em quantidade considerável, circunstâncias suficientes ao reconhecimento da procedência da ação penal, não havendo razão alguma para que os policiais incriminassem falsamente o réu. Deu especial realce para a denúncia envolvendo o nome do réu com a traficância, que se somou ao encontro dos entorpecentes. No que se refere à pena, posicionou-se por sua fixação no mínimo legal, bem como pelo reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade. Posicionou-se favoravelmente à aplicação da causa de redução de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com a substituição da pena corporal por duas penas de restritivas de direitos - prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direito (fls. 182).

A defesa buscou a improcedência da ação penal, isto em face da ausência de elementos que autorizem o reconhecimento da prática do crime pelo acusado, salientando que as narrativas policiais são insuficientes para a condenação, mesmo porque estas não teriam presenciado qualquer ato de traficância por parte do réu. Em caso de procedência da acusação, postulou pelo reconhecimento da confissão da atenuante. Ainda no campo da pena, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dizendo presentes os requisitos legais do

artigo 44 e respectivos incisos do Código Penal (fls. 207).

É o breve apanhado do processo.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do delito é certa. Submetida a substância em questão ao denominado Exame Químico Toxicológico (fls. 164), constatou-se que, de fato, cuidava-se de "cocaína", não deixando margem à dúvida de seu atributo psicotrópico, capaz de causar dependência psíquica, incluída, portanto, incluída, portanto, na Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil, constante da Portaria SVS/MS nº 344, de 12/05/98, republicada no Diário Oficial da União de 01/02/99 e a RDC nº 18, da Agência de Vigilância Sanitária, datada de 28/01/03.

Em reforço ainda há o auto de exibição e apreensão de fls. 12, o Boletim de Ocorrência de fls. 28, assim como o laudo de constatação provisória de fls. 35.

Da mesma maneira a autoria do crime em questão desponta da prova angariada de forma robusta e coesa, eis que a prova orla colhida sob o crivo do contraditório aponta sem dúvida alguma a autoria do delito por parte do acusado, que é confitente.

O Policial Civil SILVÉRIO LÚCIO DUARTE PACHECO narrou que fora acionado pela Polícia Militar para diligenciar junto à residência do acusado, isto porque o depoente tinha informações sobre sua participação na narcotraficância. Acompanhou quando os policiais militares localizaram entorpecentes no quarto utilizado pelo acusado, que morava na companhia de sua genitora, que autorizou o acesso ao imóvel - fls. 169 - audiência gravada pelo sistema Teams.

Os Policiais Militares DANILLO CESAR FELIX LINS e JONIL INÁCIO ANTUNES ALVES (fls. 171 e 172) relataram que foram alertados por populares a respeito de possível ocorrência de tráfico no local dos fatos. Assim que chegaram ao local, o réu tentou se evadir, mas acabou sendo abordado, quando localizaram a quantia de R\$ 54,50 em seu poder. Retornaram ao local onde avistaram inicialmente o réu, encontrando os entorpecentes apreendidos. Naquele momento, o réu admitiu a traficância no local, bem como admitiu ter mais drogas em sua residência. Diante dessa informação, rumaram para a casa do acusado, onde tiveram a entrada franqueada por sua genitora, logrando encontrar, no quarto usado pelo acusado, mais entorpecentes.

A própria genitora do acusado, mesmo sendo ouvida sem o compromisso legal, confirmou a autorização dada aos policiais para ingresso em sua residência, onde, no quarto usado por seu filho, foram localizados entorpecentes. Disse que tinha conhecimento de que o filho estava atuando no tráfico de drogas e que não tinha emprego - JULIANA APARECIDA RODRIGUES AGUIAR - fls. 170 - audiência gravada pelo sistema Teams.

Não resta a menor dúvida de que as drogas apreendidas naquela oportunidade pertenciam ao acusado e eram destinadas ao tráfico, inversamente do que tentou fazer crer a combativa defesa. A quantidade apreendida não é nada desprezível (num total de 52,4 gramas de cocaína e "crack"), ao contrário, principalmente porque ambos os entorpecentes apreendidos são comercializados em pequenas porções de peso quase que insignificante.

Não há como não acreditar na versão da polícia. Ressalte-se que os homens da força pública são agentes credenciados pelo Estado e como tal merecem confiança especial em seus relatos, ainda mais se coerente com a prova amealhada em juízo. De resto, a defesa não conseguiu comprovar qual a razão de eventual comportamento indigno do policial.

Afora isso, não é possível que se alegue que os testemunhos apenas de policiais não

são válidos para servir de lastro a embasar o decreto condenatório, tema já exaustivamente debatido nos tribunais, cuja conclusão majoritária é no sentido de seu total acolhimento, ainda mais se amparado em outras provas colhidas, conforme sucede na espécie.

A idoneidade dos agentes da polícia, como já frisado, é presumida e somente pode ser vencida através de prova plena e inequívoca, esta ausente na hipótese "sub judice".

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta da suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286).

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseveraram que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta da suspeição" (RT 614/275).

Não existe qualquer contradição digna de nota dos testemunhos dos policiais. Evidentemente que as versões não são idênticas e nem poderiam ser, pois do contrário soariam como uma lição decorada. Cada testemunha presencia e apreende fatos determinados. As versões idênticas soam como lição decorada, esta sim suspeita de ser tendenciosa.

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Alegadas contradições no relato dos dois policiais que apreenderam a droga com a ré - Irrelevância - Hipótese em que pequenas contradições decorrem das condições em que a prova é realizada - Importância da verificação de concordância dos depoimentos nos pontos essenciais - Não comprovação, ademais, de algum interesse que pudessem ter os policiais em incriminar a apelante - Recurso não provido. As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas contradições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante verificar se, embora discrepantes detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato" (Apelação Criminal n.155.567-3 - Santos - Relator: GONÇALVES NOGUEIRA - CCRIM 3 - v.u. - 24.10.94).

O réu, é importante deixar assentado, confessou a propriedade das drogas e a traficância, referendando, por completo, a já robusta prova testemunhal colhida - fls. 174 - audiência gravada pelo sistema Teams.

Significante também é a quantidade da substância apreendida e que não pode ser singelamente ignorada, da qual poderiam ser extraídas inúmeras pequenas porções, o que permite concluir de modo indubitado que as drogas apreendidas naquela data eram destinadas ao consumo de terceiros e que tantas famílias têm destruído ao longo dos tempos.

"Em tema de comércio clandestino de entorpecentes, relevante é a verificação da quantidade da substância proibida apreendida, a fim de se cotejar esse elemento com outras circunstâncias que envolvem a prática da infração, máxime quando se pretende provar que alguém é mero usuário e não traficante" (JUTACRIM 54/315).

"Tóxicos - Traficância - 7,24 g de cocaína e 7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade, porque permitem, respectivamente, 144, 145 "carreirinhas"....

(RJTJRS 159/192).

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Réus detidos na posse de papérolas de cocaína - Quantidade e acondicionamento da droga evidenciando o comércio ilícito - Credibilidade, ademais, do testemunho dos policiais que fizeram a apreensão - Recurso parcialmente provido" (Apelação Criminal n. 180.224-3 - São Paulo - Relator: GONÇALVES NOGUEIRA - CCRIM 3 - v.u. - 03.04.95).

"Considerados a quantidade (15g) e o valor da cocaína apreendida, em contraste com a modestíssima renda do recorrente confirmam a decisão de primeiro grau, que entendeu configurado o delito capitulado no art. 12 da Lei nº 6.368/76" (RJTJRS 145/115).

O crime definido no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 é de múltipla ação, dentre as quais estão as modalidades de trazer consigo e manter em depósito, exatamente como apontado pela acusação e efetivamente comprovado pela prova oral. Por isso mesmo irrelevante quando a defesa sustenta que os policiais não teriam presenciado qualquer "ato de traficância pelo acusado".

Da mesma forma merece prestígio a pretensão ministerial que reclama o perdimento do dinheiro apreendido, cuja origem não foi comprovada pelo acusado, o que poderia ser facilmente conseguido se realmente esse numerário fosse lícito.

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Apreensão de toneladas de acetona e éter sulfúrico destinados ao refino de cocaína - Natureza associativa da atividade dos acusados, em vasta rede nacional e ao que indica, internacional, ademais comprovada - Condenação de rigor com fixação da pena e decretação da perda dos bens apreendidos conforme o art. 34 da Lei Antitóxicos" (Relator: Dirceu de Mello - Apelação Criminal 91.096-3 - São Paulo - 11.09.91).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Perda do veículo utilizado no transporte da droga - Admissibilidade - Controvérsia quanto à propriedade do bem - Discussão afeta ao Juízo Cível - Inteligência do art. 120, § 4º, do CPP" (TRF - 3ª Reg. RT 741/725).

Assim sendo, transitada em julgado a sentença, remetam-se ao Senad relação dos valores declarados perdidos em favor da União, conforme artigo 63, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Concluindo sem sobra de dúvidas de que o réu merece a censura penal, passo agora a dosimetria da pena a ser imposta, observado o sistema trifásico previsto pela legislação penal - artigo 68 do Código Penal.

As circunstâncias judiciais definidas no artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado. Não há registros de outros envolvimento com a criminalidade (fls. 45). A quantidade de drogas apreendida, porém, está longe de ser rotulada de modesta, autorizando, portanto, o aumento previsto pelo artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que prepondera sobre o artigo 59 do Código Penal. Assim, exaspero a pena-base em 1/6, não apenas em razão da quantidade de entorpecentes, mas em razão de sua variedade - cocaína e "crack", este de poder viciante intenso e devastador - totalizando cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão.

"TÓXICOS - Tráfico - Reconhecimento com base na quantidade e variedade de entorpecente, bem como a forma de acondicionamento - Cabimento - Prisão do agente em pleno ato de comércio - Desnecessidade - Recurso parcialmente provido. PENA - Fixação - Tráfico ilícito de entorpecentes - Crime praticado a cerca de 300 metros de distância da escola mais próxima - Aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Federal nº 11343/06 - Descabimento - Local que se situa "em ponto estratégico, entre duas escolas" - Irrelevância, uma vez que a lei se refere a "imediações" - Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do

apelante" (TJSP - Ap. nº 990.09.281.993-3 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Francisco José Galvão Bruno - J. 18.03.2010 - v.u).

Na segunda fase de fixação da pena verifica-se a atenuante da menoridade do acusado, bem como da confissão, na forma do artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal. Com isso, reduzo a pena inicial em 1/5, acima do mínimo, contudo, a pena fica arbitrada em cinco (05) anos de reclusão, considerando que as atenuantes não podem reduzir a pena a quem do mínimo.

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

O artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 traz causa especial de redução de pena ao dispor que nos delitos definidos no "caput" e no parágrafo primeiro deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. A despeito das circunstâncias judiciais serem favoráveis, a prova descortinada revela que o acusado se dedica a atividades criminosas, pois guardava entorpecentes variados em sua residência, com evidente destinação mercantil. O acusado jamais fez prova de ter algum vínculo empregatício. Ao contrário. Sua genitora e ele mesmo narrou em solo judicial que o réu não tinha qualquer atividade laborativa, vivendo exclusivamente da traficância. Pessoas com o perfil do acusado são cada dia mais cooptadas pelo tráfico de drogas. No mais, dias após os fatos, o acusado foi flagrado violando as medidas cautelares que lhe foram impostas quando da concessão de sua liberdade provisória, estando na companhia de pessoa que foi presa portando entorpecentes (fls. 106). Por isso mesmo teve sua prisão preventiva decretada (fls. 110). Isso releva, sem dúvida alguma, que o réu vem se dedicando à atividade criminosa e que a prisão em flagrante de outrora não foi suficiente para prevenção ou repressão. A liberdade conquistada horas depois de ser preso com toda certeza não foi suficiente à prevenção e repressão, impulsionando o acusado ao descumprimento das medidas cautelares impostas. Evidentemente que se tiver a pena reduzida, com sua substituição por penas restritivas de direitos, isto servirá de verdadeiro estímulo à criminalidade. Em liberdade o réu não deu sinais de que a prisão fora suficiente para frear sua atividade criminosa. Ademais, seria paradoxal este juízo decretar a prisão preventiva do agente por descumprimento das medidas cautelares e substituir a pena corporal a ele aplicada.

Acrescente-se que para se beneficiar da causa especial de redução de pena o réu não deve integrar organização criminosa. O delito de tráfico é uma grande engrenagem com inúmeras peças. Vai desde o fabrico da substância entorpecente até o destinatário final que são os consumidores. Até que isso ocorra inúmeras pessoas são envolvidas nessa cadeia criminosa, o que comprova que a apreensão de quantidade elevadíssima e variada de substância entorpecente decorre de organização criminosa que tem toda uma logística, com recrutamento de várias pessoas que atuam em diferentes áreas, no caso do acusado o armazenamento em sua residência, aparentemente insuspeita. Não existe dúvida alguma de que o réu faz parte desse importante braço da organização, cujo objetivo é a venda dos entorpecentes a usuários da região, contribuindo, inegavelmente, para aumentar o público desse lucrativo negócio. Irrelevante o fato de o acusado não conhecer os demais integrantes dessa organização ou estar participando pela primeira vez (fato não comprovado), pois também faz parte do sucesso desse tipo de empreitada criminosa a separação entre os diversos componentes da organização. O acusado sabe muito bem que para que a droga chegue até ele tem que passar por outros integrantes da organização. Ao ser indagado em seu interrogatório de quem teria adquirido a droga, o acusado sequer respondeu, ficando mais do que evidente que tem conhecimento da origem da droga e de que esta está ligada à organização criminosa. Por conta disso tudo, não merece a redução da pena.

"HABEAS CORPUS - Penal - Tráfico transnacional de drogas - Dosimetria da pena

devidamente fundamentada - Aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 - Impossibilidade - Réu integrante de organização criminosa - Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito - Ausência de requisito objetivo - Ordem denegada. O indeferimento da causa especial de redução do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo sérios indícios de que o paciente integra organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas, o que impede a concessão da própria benesse. Ordem denegada" (STF - HC nº 111.398 - SP - 2ª T. - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - J. 17.04.2012 - DJE 03.05.2012).

"Para que a redução da pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei 11.343/2006 seja concedida, não basta que o agente seja primário e tenha bons antecedentes, sendo necessário, também, que ele não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Com base nesse entendimento, a Turma desproveu recurso ordinário em habeas corpus no qual se pleiteava a incidência da referida causa especial de diminuição de pena a condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes na vigência da antiga Lei de Tóxicos (Lei 6.368/76, artigo 12). Aduziu-se que, na espécie, a dedicação do recorrente ao tráfico de drogas ficara devidamente comprovada nos autos e que não fora afastada pela defesa na apelação e nas demais impetrações posteriores. Os Ministros Marco Aurélio e Carlos Britto também denegaram o recurso, mas por fundamento diverso, consentâneo com a óptica do tribunal estadual, no sentido de que o aludido parágrafo quarto do artigo 33 da Lei 11.343/2006 não se aplica à situação concreta regida pela Lei 6.368/76, sob pena de se olvidar o critério unitário, chegando ao conglobamento com o surgimento de uma nova regra normativa" (STF - RHC nº 94.802 - RS - Rel. Min. Menezes Direito - J. 10.02.2009).

"TÓXICOS - Tráfico - Afastamento da benesse prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Cabimento - Condenados encontrados em atividade criminosa - Quantidade de drogas indicativa de relacionamento estreito dos réus com o crime organizado - Recursos dos réus desprovidos e recurso ministerial provido" (TJSP - Ap. nº 990.10.045.033-6 - Botucatu - 9ª Câmara de Direito Criminal - Rel. José Orestes de Souza Nery - J. 05.08.2010 - v.u).

"PENA - Redução - Prática de tráfico de entorpecentes - Aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 - Inadmissibilidade - Hipótese em que, embora o réu seja primário e não registre maus antecedentes, mostrou comportamento voltado ao delito, não sendo recomendável a adoção dessa medida, que, aliás, é de caráter facultativo, uma vez que a norma legal dispõe que "as penas poderão ser reduzidas", ficando ao prudente arbítrio do Julgador essa análise no caso concreto - Recurso improvido" (Apelação Criminal n. 1.156.870-3/6 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Marco Antonio - 13.3.2008 - V.U.- Voto n. 7.100).

Não sendo encontradas outras causas, especiais ou gerais, de aumento ou diminuição de pena, torno a fixada em definitiva.

A multa prevista de forma cumulativa deve ser fixada dentro dos mesmos critérios para o encontro da pena-base, inclusive com o acréscimo resultante do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. No tocante ao valor, deve-se ter em mira o conteúdo do artigo 43, "caput", da Lei nº 11.343/06, sempre no mínimo legal frente à situação econômica nada privilegiada do réu, atualmente encarcerado.

O cumprimento da pena deve ser feito inicialmente no regime FECHADO. O crime de tráfico, além de ser equiparado aos delitos hediondos, é sempre grave, justamente porque atinge a saúde pública. Além do mais, fomenta uma série de outros delitos graves, inclusive o tráfico de armas e os crimes patrimoniais violentos, amiúde cometidos por usuários. Por conta disso, a resposta à sociedade por parte do Poder Judiciário deve ser austera, sob pena não se criarem mecanismos de inibição ao cometimento desse grave delito. No caso dos autos ficou claro que as medidas

diversas da prisão são insuficientes para conter a atividade criminosa do acusado que, mesmo dias depois de ser preso e contemplado com a liberdade provisória, foi pilhado descumprindo as medidas impostas e na companhia de pessoa flagrada com entorpecentes. Assim, o regime de menor intensidade soaria ao réu e a seus pares como verdadeiro incentivo à criminalidade, que grassa cada vez mais, muito por conta da leniência na aplicação da lei. Ademais, a quantidade de drogas não pode ser desprezada quando da fixação do regime carcerário. Por fim, a figura do tráfico "privilegiado" restou afastada, circunstância que mantém a condição de hediondo do crime.

"PENA - Regime - Fixação - Tráfico de entorpecentes - Com o advento da Lei nº 11.464/07, o regime de cumprimento de pena não pode mais ser o integralmente fechado, modalidade assinada somente para a fase inicial de cumprimento - Recurso provido" (Apelação Criminal nº 1.039.230-3/2 - Catanduva - 8ª Câmara do 4º Grupo da Seção Criminal - Relator: Lourival Barbiero - 11.9.07 - V.U. - Voto nº 2.439).

"TÓXICOS - Regime prisional - Tráfico - Fixação da modalidade inicial fechada - Necessidade, nos termos da Lei n. 11.464/07 - Regime integral fechado - Descabimento - Recurso parcialmente provido para estabelecer o regime prisional inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade" (Apelação Criminal n. 1.060.484.3/0 - Santos - 9ª Câmara Criminal - Relator: René Nunes - 26.09.07 - V.U. - Voto n. 10.932).

"Habeas Corpus: Tráfico de drogas. Adoção do regime fechado para início do cumprimento da pena de reclusão. Alegação de violação às Súmulas 718 e 719 do STF. Inocorrência. Fundamentação sobre a gravidade concreta do crime. Possibilidade de utilização da quantidade de drogas para fixação de regime mais gravoso (STJ). Ordem denegada" (TJSP - Habeas Corpus Criminal 2034881-03.2022.8.26.0000; Relator (a): Bueno de Camargo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaberá - Vara Única; Data do Julgamento: 24/03/2022; Data de Registro: 24/03/2022).

A regra contida no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal não altera o regime carcerário levando-se em consideração o tempo de prisão preventiva do acusado, pois ainda não cumpriu o requisito temporal para obtenção de progressão de regime (artigo 2º, inciso II, da Lei nº 8.072/90). Além disso, o artigo 112 da Lei de Execução Penal exige, além do requisito objetivo para a progressão (tempo de cumprimento da pena), bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão, informações estas que não constam dos autos, impedindo, portanto, a fixação do regime menos severo.

"(...) No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei n.º 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena (...)" (TJ/SP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n.º 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. Alberto Mariz de Oliveira, j. em 04.06.2013).

"Pena - Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP - Entendimento. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou

não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença" (Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Mogi-Guaçu; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 11/08/2016; Data de registro: 16/08/2016).

Pela ausência de pressuposto objetivo (quantidade da pena) e a hediondez do crime, é negado ao réu o benefício do "SURSIS" (artigo 77, "caput", do Código Penal).

Também não merece ser agraciado com nenhuma das penas alternativas previstas pelo artigo 43 do Código Penal introduzidas pela Lei nº 9.714/98.

Ocorre que a pena aplicada ultrapassa, em muito, o pressuposto objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal, inviabilizando por completo a substituição. Por fim, a substituição mostra-se absolutamente incompatível com a gravidade do delito e sua condição de equiparado aos hediondos, não sendo, portanto, socialmente recomendável, lembrando que a inconstitucionalidade de parte do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal diz respeito unicamente ao chamado "tráfico privilegiado" [Habeas Corpus nº 97.256/RS], descartado no caso dos autos, considerando que o réu não tem emprego e se dedica a atividades criminosas.

Veda-se ao réu o apelo em liberdade. Primeiro porque que aguardou o desfecho da instrução segregado, sendo que agora, depois de condenado, a soltura seria verdadeiro paradoxo. Segundo porque o singelo fato de ser primário não pode autorizar esse tipo de benefício, que deve ser reservado apenas aos crimes de menor gravidade e que não provoquem alarma social, ao contrário do que ocorre com o tráfico de entorpecentes, delito equiparado aos hediondos e de gravidade singular. A libertação do inculcado serviria de estímulo à criminalidade e não se prestaria a colocar freio na vertiginosa onda de crimes que assola e atemoriza nossa sociedade, principalmente o tráfico de drogas, que tem destruído inúmeras famílias. Além disso, conforme já sublinhado, os pressupostos e fundamentos que autorizam a prisão preventiva estão presentes, havendo efetivo risco para a aplicação da lei penal, notadamente em virtude da condenação e da pena elevada imposta ao agente. As demais medidas cautelares previstas pelo artigo 319 e incisos do Código de Processo Penal não foram suficientes à gravidade do delito e, em especial, à condição pessoal do acusado, conforme exigido pelo artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Tanto isso é verdade que as descumpriu. Observo que o crime imputado ao agente tem pena máxima que ultrapassa a quatro anos de prisão, permitindo, portanto, a custódia cautelar (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). A gravidade do delito é concreta e a libertação do acusado, principalmente nesta fase do processo, com pena aplicada, soaria a todos, inclusive a ele, como impunidade. No mais, ficam reiterados os argumentos empregados por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva, pois perfeitamente válidos ao caso - fls. 110.

"CONSTRANGIMENTO ILEGAL - Tráfico de entorpecente - Condenação - Regime inicial fechado - Crime Hediondo - Negado o apelo em liberdade - Legalidade - Não caracterização - Perniciosidade do tráfico que justifica a continuidade da segregação - Ordem denegada" (Habeas Corpus n.º 247.004-3 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal de Férias de Janeiro/98 - Relator: Segurado Braz - 14.01.98 - V.U.).

"HABEAS CORPUS - Réu preso em flagrante e condenado por prática de crime hediondo, tráfico de entorpecentes, que recorreu da sentença e que pretende liberdade provisória para aguardar o resultado do julgamento - Alegação de que necessita de tratamento médico - Irrelevância - Obrigação do Estado de fornecer o aludido tratamento - Artigo 35 da Lei 6.368 de 1976, que manteve a permanência na prisão

como condição do apelo - Ordem denegada" (Habeas Corpus n.º 259.177-3 - Barretos - 6ª Câmara "JULHO/98" de Direito Público - Relator: Debatin Cardoso - 22.07.98 - V.U.).

"Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida" (JTACRESP 42/58).

"A garantia da ordem pública, dada como fundamento da decretação da custódia cautelar, deve ser de tal ordem que a liberdade do réu possa causar perturbações de monta, que a sociedade venha a se sentir desprovida de garantias para a sua tranquilidade" (RDJTACRIM 11/201).

Importante deixar assentado que a negativa quanto ao direito de apelar em liberdade não está fundada na regra do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 104.339-SP, mas na existência de pressupostos e fundamentos que autorizam a prisão preventiva, conforme acima registrado e que também foram levados em consideração no momento em que se decretou a prisão cautelar.

Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a Ação Penal para CONDENAR o acusado PEDRO RODRIGUES AGUIAR (R.G. nº 58.907.963) por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco (05) anos de reclusão (REGIME FECHADO) e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor de um trinta avos do maior salário mínimo vigente (salário mínimo paulista), na forma prevista pelo artigo 43 da Lei nº 11.343/06, bem como o perdimento do dinheiro, na forma do artigo 63, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no livro destinado ao rol dos culpados, oficiando-se para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Recomende-se o réu na prisão em que estiver recolhido.

P.I.C.

LUIZ HENRIQUE ANTICO
Juiz de Direito

Roseira, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA